

1501626-94.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... "Matheus" que estariam praticando o narcotráfico no local acima mencionado, razão pela qual rumaram ao referido endereço. Lá chegando, visualizaram os acusados, os quais possuíam as mesmas características informadas, praticando ato típico de tráfico. Porém, ao notar a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, mas foram abordados.

Na sequência, realizaram buscas e encontraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501626-94.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 120/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2289382/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2289382 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 120/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Messias Matheus Aparecido Pires Cândido e outro

Réu Preso

Contr. nº 2021/001139

Aos 19 de janeiro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dra Sandra Regina Ferreira da Costa foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presentes os réus MESSIAS MATHEUS APARECIDO PIRES CANDIDO e MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA (preso CDP local). Presente a defensora Dra. Mariane Campos da Silva Bacchin. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PCs Leornado Calvacanti de Oliveira e Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira. Presente(s) a(s) testemunha de defesa: Gabriel Felipe Barbosa.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, através de exibição à câmera de documento original com foto, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (PCs Marcelo e Leonardo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra a Defesa foi dito que desistia da oitiva da(s) testemunha Gabriel, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS - GRAVADAS EM ÁUDIO E VÍDEO.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS - GRAVADAS EM ÁUDIO E VÍDEO.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

MESSIAS MATHEUS APARECIDO PIRES CANDIDO e MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 11,45 horas, na favela Cananéia, situada na Rua Cananéia, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustados, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 0,5g de cocaína, distribuídos em 02 "eppendorfs", 3,9g de Cannabis sativa L., distribuídos em 03 invólucros, 127,7g da mesma droga, distribuídos em 105 invólucros, e 17,3g de cocaína distribuídos em 65 "eppendorfs", substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais receberam informações e a descrição de dois indivíduos de nome "Matheus" que estariam praticando o narcotráfico no local acima mencionado, razão pela qual rumaram ao referido endereço. Lá chegando, visualizaram os acusados, os quais possuíam as mesmas características informadas, praticando ato típico de tráfico. Porém, ao notar a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, mas foram abordados.

Na sequência, realizaram buscas e encontraram na posse de Messias Matheus 03 porções de maconha e a quantia de R\$30,00 proveniente do narcotráfico, enquanto com Matheus Silva 02 "eppendorfs" de cocaína e o valor de R\$60,00, oriundo da mercancia ilícita. Em seguida, realizaram diligências nas proximidades e localizaram 105 invólucros de maconha semelhantes àqueles encontrados na posse de Messias e 65 "eppendorfs" de cocaína idênticos àqueles localizados na posse de Matheus.

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 168 e fls. 171). Defesa preliminar apresentada às fls. 173/176. Após, a denúncia foi recebida (fls. 184) e os réus foram citados às fls. 249 e fls. 251.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autorias e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição dos acusados, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

1) Boletim de ocorrência de fls. 09/11;

2) Auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e fotografias de fls. 14; e
3) Laudo de constatação de fls. 18/24 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 150/153, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05/06 e 07/08), os réus exerceram o direito de permanecer em silêncio. Apenas afirmaram que as drogas não eram suas e que não estavam traficando.

Interrogado em juízo (gravação), o réu Messias disse que, no dia dos fatos, saiu de casa, comprou cigarro no bar e após foi a um churrasco. Pediu para um menino maconha para usar. Logo após, Matheus desceu a escada e ficaram conversando. A viatura se aproximou. Os traficantes que atuavam no local correram, mas os policiais abordaram apenas ele e Matheus. Após o cachorro encontrou as drogas escondidas nas proximidades, as quais, entretanto não lhes pertenciam. Admitiu que portava 3 porções de maconha e R\$ 30,00. Disse que fazia 14 dias que tinha saído de uma prisão por tráfico também e que mora próximo do local dos fatos.

No interrogatório judicial (gravação), o réu Matheus apresentou a mesma versão, admitindo apenas que portava duas porções de cocaína para seu uso.

As negativas foram afastadas pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e em juízo (gravação), o policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira declarou que, no dia dos fatos, receberam informação de um colaborador local de que dois indivíduos, ambos de nome "Matheus", com tatuagens no pescoço, trajando camisa de time de futebol do bairro e bermuda, sendo que um estava de boné, estavam comercializando entorpecentes na entrada da Viela Dois, da Comunidade Cananéia, no bairro Monte Líbano, local muito conhecido como ponto de tráfico. Dirigiu-se para lá com o policial civil Bruno, onde permaneceram mais distantes em viatura caracterizada. Por sua vez, o policial Leonardo, que se manteve no local em observação velada, utilizando viatura descaracterizada, constatou rapidamente a mercancia de entorpecentes pelos dois réus, os quais tinham as características e trajavam as roupas indicadas pelo denunciante. O policial Leonardo narrou que os dois atendiam usuários, afastavam-se por alguns segundos (Matheus acessava a viela 1 e ali o perdia de seu campo visual e Messias acessava a viela 3 por uma escada), retornando logo em seguida e trocando algo com os usuários. Assim, dirigiu-se até o local, desembarcou na Avenida Raposo Tavares e desceu a Viela Um a pé, enquanto o policial Bruno adentrou a via principal com a viatura caracterizada. Ao chegar no final da Viela Um e acessar a Viela Dois, surpreendeu os réus, quando estes tentavam fuga após visualizarem a aproximação da viatura caracterizada. Os dois foram algemados e colocados ao solo, visando cessar qualquer nova possibilidade de fuga, pois inicialmente estava sozinho. Em revista pessoal, localizou R\$ 30,00 em espécie e 3 porções de maconha no bolso do indivíduo que usava boné, identificado como sendo Messias Matheus Aparecido Pires Candido. No bolso do segundo indivíduo, identificado como sendo Matheus Silva de Oliveira, encontrou R\$ 60,00 e 2 porções de maconha, sendo que ambos alegaram serem usuários e que correram porque se assustaram com a viatura, mas não estavam traficando. Em seguida, utilizando cão de faro "Eagle", realizou buscas nas vielas 1 e 3 que eram acessadas por eles durante a campana. O cão localizou na escada que Messias acessava um saco de salgadinho contendo 105 porções de maconha, semelhantes àquelas localizadas na posse dele. Ademais, na viela 1, no local que Matheus acessou durante a campanha localizou um pote de gel contendo 65 porções de cocaína, embaladas de maneira idêntica, "eppendorfs" verdes, àquelas localizadas na sua posse. Após informar aos réus que eles estavam sendo monitorados veladamente, ambos confessaram que estavam traficando, justificando que estavam desempregados. Por fim, informou que, no local, havia várias pessoas, mas no ponto de tráfico eram somente os réus e foram eles que correram com a chegada da polícia, eram eles que tinham as características informadas e eles foram vistos em atitude típica de tráfico pelo policial Leonardo.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira.

Anoto que os relatos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação dos acusados em detrimento da palavra dos policiais civis: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daqueles é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que os réus, previamente ajustados, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes descritos na denúncia, substâncias estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, em que pese as negativas dos acusados, a prova oral foi muito segura no sentido de que, após receberem informações de tráfico no endereço da denúncia, policiais realizaram campana no local, o policial Leandro com viatura descaracterizada e os policiais Marcelo e Bruno em viaturas caracterizadas mais distantes. O policial Leandro observou movimentação típica de tráfico de drogas, onde os acusados atendiam usuários, saíam do seu campo visual por alguns segundos e retornavam logo em seguida trocando algo com aquelas pessoas.

Ademais, durante a diligência, ao perceberem a presença da viatura policial caracterizada, os acusados tentaram se evadir, sendo surpreendidos pelo policial Marcelo que estava a pé. Quando informados que estavam sendo monitorados, confessaram, informalmente, que estavam vendendo as drogas, pois estavam desempregados.

Com eles foram encontradas porções de maconha e cocaína, embaladas de forma idêntica às demais drogas localizadas nas proximidades, mais especificamente nas vielas que eles acessavam quando mantinham contato com o usuário e voltavam para lhes entregar algo.

Diante disso, não há dúvidas de todos os entorpecentes pertenciam a eles, que, naquele dia e horário, eram os responsáveis pelo tráfico no local.

Registro que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade de drogas (143 porções de maconha e 74 "eppendorf" de cocaína), incompatível com a situação de meros usuários e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas.

Além disso, com os réus havia dinheiro, o qual, diante das circunstâncias da apreensão, evidentemente era produto do crime, até mesmo porque não comprovada a origem lícita.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esgota a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a pena é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal

- Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.
"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação dos réus pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, razão pela qual fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência (cf. processo criminal nº 473-37.2020, fls. 47/48, condenação definitiva aos 23/10/2020) em desfavor do réu Messias e, por outro lado, a atenuante da menoridade.

Como ambas as circunstâncias são consideradas preponderantes, deixo de aumentar ou diminuir as suas penas na segunda fase.

Em relação ao réu Matheus inexistem agravantes e atenuantes.

Não se fazem presentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao réu Messias, registro que a reincidência, que, inclusive, é específica, impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal (as quais também são incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do

regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017).

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Em relação ao réu Matheus, também não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, embora primário, possui diversas passagens na Vara da Infância e Juventude, havendo duas condenações também por tráfico de drogas, uma delas com aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida (fls. 230/232) e a outra, mais gravosa, com aplicação de internação (fls. 245/247), o que, aliado ao fato de não ter comprovado exercer atividade lícita e guardar e trazer consigo expressiva quantidade de drogas, demonstra que vem se dedicando a esta atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, não podendo ser equiparado aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas desde a adolescência, não comprovando atividade lícita e guardando e trazendo consigo expressiva quantidade de entorpecente.

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram

as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitativa, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 10. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração das majorantes para 1/6, ficando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. PASSAGENS ENQUANTO MENOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA TOTAL SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.

GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pelo fato do paciente ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. In casu, resta evidenciado o constrangimento ilegal na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, a fixação foi em razão da hediondez e da gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior, mormente se considerarmos que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (uma porção de maconha com peso de 39,16g). Dessa forma, considerando, ainda, que o paciente é primário, bem como o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), correta a fixação do regime semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias superior a 4 anos, o pleito quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena do paciente". (HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram, fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso com considerável quantidade de cocaína - 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4. Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito anos (Súmula nº 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida". (HC 212.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j. em 15/09/2011). Incabível, assim, o privilégio.

Quanto ao regime de pena, rendendo-me ao posicionamento das duas Turmas do C. STJ, conforme julgados supra citados, deixo de fixar o fechado, como vinha fazendo, para eleger o semiaberto, eis que a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância. No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha reiterando nas atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Ademais, o crime de tráfico de drogas tem graves consequências, fomentando a prática de vários outros delitos, destruindo famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Necessária, assim, a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu Matheus sentisse as consequências de seu grave ato e, considerando que já vem traficando há algum tempo, desde que era menor de idade, muito provavelmente continuaria a realizar o nefasto comércio.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto os réus estão presos há menos de três meses, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de pena.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas dos réus.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu MESSIAS MATHEUS APARECIDO PIRES CANDIDO a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

2) CONDENO o réu MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que os valores apreendidos em poder dos acusados é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Diante da reincidência do réu Messias, inclusive, específica, bem assim, o envolvimento pregresso do acusado Matheus com a prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, e considerando a maior gravidade do crime em comento, considerado hediondo, verifica-se maior gravidade de suas condutas e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual fica mantida.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário.

Recebo o recurso interposto. Desde já sai a defesa intimada do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e

gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.